

1501679-18.2022.8.26.0542

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: ULISSES AUGUSTO PASCOLATI JUNIOR

Comarca: Osasco

Foro: Foro de Osasco

Vara: 4ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 05/10/2022

... e duradoura, a atividades criminosas ligadas ao tráfico. Este requisito poderia restar demonstrado caso tivesse havido maiores investigações pela autoridade policial, o que não ocorreu no caso em apreço.

Anoto que a quantidade de drogas, por si só, sem outras investigações não permite a conclusão de dedicação da ré à atividade ligada ao tráfico. Nesse sentido:

AGRAVO ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Osasco

Foro de Osasco

4ª Vara Criminal

Av. Das Flores, 703, Osasco - SP - cep 06110-100

1501679-18.2022.8.26.0542 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1501679-18.2022.8.26.0542

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MICHAEL CRISTIAN DA SILVA GARCIA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ULISSES AUGUSTO PASCOLATI JUNIOR

Vistos.

Trata-se de ação penal na qual MICHAEL CRISTIAN DA SILVA GARCIA, foi denunciado como incurso nas penas do artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/06.

Narra a Denúncia (fls. 56/58) que, no dia 18 de julho de 2022, por volta das 08h32min, na Rua Pereira Barreto, altura do n.º 255, Munhoz Jr., nesta cidade e comarca de Osasco, MICHAEL CRISTIAN DA SILVA GARCIA, qualificado à fl. 13, trazia consigo drogas, para entrega ao consumo de terceiros, consistentes em 34 (trinta e quatro) porções de cocaína na forma de crack, com peso líquido de 14,1 gramas, 59 (cinquenta e nove) porções de Cannabis sativa L (maconha), com peso líquido de 99,4 gramas, e 130 (cento e trinta) porções de cocaína, com peso líquido de 42,3 gramas, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, conforme auto de exibição e apreensão à fl. 10, laudo de constatação às fls. 18/21, fotografias às fls. 24/27 e laudo de exame químico-toxicológico às fls. 48/50.

Segundo o apurado, policiais militares realizavam patrulhamento, quando avistaram o denunciado com uma mochila nas costas e ele, ao perceber a presença policial,

demonstrou nervosismo e passou a andar mais rapidamente, o que gerou suspeita e ensejou a abordagem.

Indagado sobre o que carregava na mochila, o denunciado começou a gaguejar e alegou que era usuário de drogas e havia encontrado a bolsa próximo a um poste de energia, em via pública.

Em vistoria na aludida mochila, os agentes da lei encontraram 130 (cento e trinta) porções de cocaína, 34 (trinta e quatro) porções de crack e 59 (cinquenta e nove) porções de maconha, além da quantia de R\$ 172,00 (cento e setenta e dois reais). No bolso da calça do denunciado, foi ainda encontrado um aparelho celular.

Considerando a quantidade/variedade de entorpecentes e as circunstâncias de sua apreensão, incluindo a atitude suspeita do denunciado ao notar a presença policial e o encontro também de quantia em dinheiro, é certo que as drogas se destinavam a entrega ao consumo de terceiros.

Auto de prisão em flagrante às fls. 01/02.

Auto de exibição e apreensão às fls. 10.

Laudo de constatação às fls. 18/21. Laudo definitivo às fls. 48/50.

Folha de antecedentes às fls. 33/35.

Em decisão de fls. 64/72, procedeu-se à conversão do rito especial previsto na Lei 11.343/06 para o rito ordinário do Código de Processo Penal e a denúncia foi integralmente recebida. Ainda, foi concedida liberdade provisória ao acusado. Alvará de soltura cumprido às fls. 81/83.

Em razão de recurso interposto pela Acusação, sobreveio decisão liminar do E. Tribunal de Justiça de São Paulo, sendo concedido efeito suspensivo ao recurso e decretada a prisão preventiva de MICHAEL CRISTIAN DA SILVA GARCIA. Mandado de prisão cumprido em 02.08.2022, conforme fls. 121/124.

Citado às fls. 136, o acusado apresentou resposta à acusação por intermédio da Defensoria Pública (fls. 141/142).

O recebimento da denúncia foi mantido às fls. 145/146, mesma oportunidade em que foi designada audiência PRESENCIAL de instrução, debates e julgamento para o dia 04.10.2022, às 13h30.

Em audiência de instrução foram ouvidas as testemunhas de acusação e o réu, ao final, interrogado.

Em debates a Acusação pediu a condenação nos termos da inicial.

Em debates, a defesa não fez considerações quanto ao mérito. Alertou para a confissão, o redutor do parágrafo 4º, a primariedade e regime aberto.

É relatório.

Fundamento e decido

A - Preliminarmente, anoto que não se verifica ilegalidade na conduta dos policiais a ponto de tornar a prova ilícita. A abordagem policial não foi tão somente baseada em "tirocínio" dos agentes públicos ou somente em "nervosismo", o que denotaria o mais puro subjetivismo, mas sim em comportamento efetivo, vale dizer, porque o réu, ao sair do prédio com a mochila nas costas, apresentou comportamento titubeante ao

ver a viatura policial. Anote-se que os policiais já haviam passado pelo local, o réu ingressado no prédio e, ao sair, novamente avistou a viatura. Assim, cumprido o standard do art. 244 do CPP para atuação policial.

B - Do mérito

B.1 - Valoração probatória de autoria e materialidade

Consto a que a análise das premissas fáticas expostas na inicial pelo Ministério Público para justificar a pretensão de condenação serão consideradas tanto sob a ótica do tipo penal, quanto das provas orais valoradas em contraditório judicial. Em outras palavras, buscar-se-á uma reconstrução fático-probatória que se aproxime da verdade e que vá além de qualquer dúvida razoável e possa justificar, ao final, a imposição de pena.

Encerrada a instrução do feito, depreende-se que a reconstrução fático-probatória é suficiente para a demonstração dos elementos do tipo penal (art. 33, "caput" da Lei 11.343/06) tanto na dimensão objetiva quanto subjetiva.

A existência material do crime restou demonstrada nos autos por meio do boletim de ocorrência (fls. 03/06), auto de exibição e apreensão (fls. 10), laudo de exame químico-toxicológico (fls.) e fotografias (fls. 26/27).

Quanto a imputação de autoria, tem-se que as provas valoradas em contraditório judicial permitem com a segura e devida convicção o decreto condenatório do réu em relação ao delito de tráfico (art. 33 "caput"), eis que o réu, de fato, considerando a forma de acondicionamento, variedade e quantidade, ainda que pequena, trazia entorpecentes destinado a terceiras pessoas.

O réu ouvido em juízo confessou a autoria delitiva. Disse que, por estar desempregado, aceitou levar a mochila que pegou na Av. Diretriz até o Jardim Santa Cecília, pela quantia de R\$ 120,00 reais, sabendo o que havia em seu interior. Relatou, ainda, que, ao ver os policiais, os quais pelo local já haviam passado, entrou novamente para dentro do prédio na Av. Pereira Barreto.

Pois bem. As provas produzidas em juízo pelo Ministério Público, corroboradas pelos elementos materiais (laudo e fotografias), além da confissão do réu, permitem a superação da presunção constitucional para além de qualquer dúvida razoável.

Os policiais, em resumo, e essencialmente, afirmaram que faziam patrulhamento pelo local quando avistaram o réu com um grande volume dentro de uma mochila nas cotas. O réu, ao ver a viatura, apresentou um comportamento hesitante quando saía do prédio. Em razão deste comportamento realizaram a abordagem. Com o réu nada foi encontrado, contudo, no interior da mochila havia drogas ("maconha" e "cocaína") e dinheiro.

Inicialmente, na fase de valoração, não há porquê se duvidar da versão dos policiais. A qualidade de policial, por si só, não infirma a prova ou a torna mais importante. Não é por que a pessoa é policial e que participou da ocorrência que sua versão ganha mais ou menos credibilidade. A credibilidade da versão apresentada deve ser valorada de forma racional de maneira a verificar se ela possui coerência interna e, ainda, se possui coerência externa quando corroborada com as demais provas apresentadas.

As testemunhas policiais, em essência, não discrepam em suas versões, possuem linearidade e, também, reciprocamente são coerentes e, acima de tudo, estão consentâneas com as demais provas produzidas, especialmente as materiais e com a própria confissão do réu.

Portanto, a premissa fática do Ministério Público, qual seja, que no dia 18 de julho de 2022, por volta das 08h32min, na Rua Pereira Barreto, altura do n.º 255, Munhoz Jr., nesta cidade e comarca de Osasco, MICHAEL CRISTIAN DA SILVA GARCIA, qualificado à fl. 13, trazia consigo drogas, para entrega ao consumo de terceiros, consistentes em 34 (trinta e quatro) porções de cocaína na forma de crack, com peso líquido de 14,1 gramas, 59 (cinquenta e nove) porções de Cannabis sativa L (maconha), com peso líquido de 99,4 gramas, e 130 (cento e trinta) porções de cocaína, com peso líquido de 42,3 gramas está devidamente comprovada nos autos.

As provas demonstram, para além de qualquer dúvida, de fato, a conduta de trazer consigo entorpecente, sem autorização legal e regulamentar, de forma consciente, e que as drogas seriam para consumo de terceiros, tendo em vista a forma como acondicionadas, a quantidade e as condições nas quais se desenvolveu a ação (o réu ao ver os policiais tentou disfarçar e deixar o local). Não há dúvidas, portanto, que a droga estava com o réu - em uma mochila - e se destinava ao comércio espúrio. Em que pese haver pequenas divergências nos depoimentos e o fato do réu não ter interagido com outras pessoas para venda de drogas, estes pontos não são capazes de infirmar a prova produzida e afastar a responsabilidade penal.

B.2 - Redutor de pena

Dispõe o art. 33, § 4º da Lei n. 11.343/06: § 4º Nos delitos definidos no caput e no § 1º deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.

A lei estabeleceu 4 critérios para verificação do merecimento ou não do redutor de pena. Dois critérios afirmativos e dois negativos. Quanto aos afirmativos o réu deve ser primário, cuja verificação técnica se dá na forma do art. 64 do Código Penal e ser portador de bons antecedentes (fls. 33/35). Por outro lado, quanto aos critérios negativos, o réu não pode se dedicar às atividades criminosas ou integrar organização criminosa.

Relativamente às atividades criminosas, depreende-se que o legislador exige uma relativa habitualidade, uma reiteração de condutas, o que deve ser extraído dos elementos probatórios disponíveis nos autos. No caso em tela, não há qualquer elemento que demonstre que o réu se dedique, de forma pressuposta e duradoura, a atividades criminosas ligadas ao tráfico. Este requisito poderia restar demonstrado caso tivesse havido maiores investigações pela autoridade policial, o que não ocorreu no caso em apreço.

Anoto que a quantidade de drogas, por si só, sem outras investigações não permite a conclusão de dedicação da ré à atividade ligada ao tráfico. Nesse sentido: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO POR TRÁFICO INTERESTADUAL DE DROGAS. INCIDÊNCIA DA CAUSA ESPECIAL DE REDUÇÃO DE PENA PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006. POSSIBILIDADE. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA NÃO DEMONSTRADA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - A quantidade de entorpecente isoladamente utilizada pelo Tribunal de Justiça local não é suficiente para presumir a dedicação do recorrente à atividades ligadas à traficância e, assim, negar-lhe o direito à minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, mormente porque o magistrado sentenciante reconheceu sua primariedade, enfatizando que ele "não registra antecedentes, tampouco existem provas nos autos de dedicação a atividades criminosas". II - Agravo regimental a que se nega provimento. (RHC 148579 AgR, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 09/03/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-053 DIVULG 19-03-2018 PUBLIC 20-03-2018)

Por fim, a lei estabelece que não tem direito ao redutor o sujeito que integrar organização criminosa. Ora, com mais razão este critério negativo deve ser

afastado. Integrar significa fazer parte ou pertencer à organização criminosa. Entretanto, a conduta de integrar exige a verificação de uma questão pressuposta, qual seja: que exista uma organização criminosa. A Lei n. 12.850/2013, no art. 1º, §1º, após muito debate doutrinário e jurisprudencial e influenciada, é verdade, pela Convenção de Palermo, estabeleceu um conceito de organização criminosa, segundo o qual: “§ 1º Considera-se organização criminosa a associação de 4 (quatro) ou mais pessoas estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, com objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais cujas penas máximas sejam superiores a 4 (quatro) anos, ou que sejam de caráter transnacional”.

A demonstração dos requisitos do conceito legal, em primeiro lugar, exige investigação por parte das agências de persecução, o que não há no caso em tela. Em segundo lugar, a partir da própria tipificação legal, exigem-se os seguintes requisitos objetivos para a configuração da organização criminosa: (i) a presença de 4 (quatro) ou mais pessoas; (ii) a verificação de uma estrutura ordenada; (iii) a divisão de tarefas entre os indivíduos componentes da referida estrutura, ainda que de maneira informal; (iv) a finalidade de obtenção, direta ou indiretamente, de vantagem de qualquer natureza; e (v) a prática de infrações penais cujas penas máximas sejam superiores a 4 (quatro) anos, ou que sejam de caráter transnacional, a fim de obter as vantagens em questão.

Assim, observa-se que a organização criminosa tem características próprias e específicas, demandando a verificação in concreto dos cinco requisitos supramencionados para a sua caracterização e consequente justificação do acréscimo de pena. Necessário, portanto, elementos mínimos que demonstrem os cinco requisitos até para que se não banalize esta figura jurídica.

No caso dos autos, não há qualquer mínimo elemento que demonstre de forma pressuposta envolvimento com organização criminosa.

C - Da dosimetria da pena

Reconhecida a responsabilidade penal, observando o roteiro legal-dogmático do art. 68 do Código Penal, passo a aplicar a pena.

Na primeira fase da dosimetria da pena, considerando o art. 42 da Lei 11.343/2006 e o art. 59 do Código Penal, com preponderância daquele, fixo a pena base em 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, eis que a quantidade de drogas é não significativa e, ainda, o ré é primário e não ostenta antecedentes.

Na segunda fase, em que pese a confissão, a pena fora fixada no mínimo legal.

Na terceira fase, diante da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, e presentes os pressupostos afirmativos e ausentes os negativos, diminuo a sanção em 2/3 fixando-a, em definitivo, em 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e 167 dias multa.

O réu preenche os requisitos do art. 44 do Código Penal, posto que não é reincidente em crime doloso, o crime não é praticado com violência ou grave ameaça e, no caso do tráfico, a vedação de conversão foi julgada inconstitucional (HC 97.256/RS) e, ainda, o fato de que a substituição se mostra suficiente e a medida é recomendável, substituo a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos mais multa.

A restritiva de direitos consiste no cumprimento de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de prestação de serviços à comunidade ou entidade pública na forma a ser disciplinada pelo Juízo das Execuções Criminais, conforme art. 46 do Código Penal. A multa, por

sua vez, consiste no pagamento de 10 dias-multa.

Somando-se as multas chega-se ao total de 177 dias-multa.

Cada dia-multa será fixado no mínimo, na ausência de maior conhecimento das condições econômicas do réu.

Caso haja necessidade do cumprimento de pena corporal, o regime será o aberto (art. 33, parágrafo 2º, alínea "c").

D- Do dispositivo:

Diante do exposto, julgo procedente o pedido da presente ação penal e: CONDENO MICHAEL CRISTIAN DA SILVA GARCIA, qualificado nos autos, ao cumprimento de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, em regime aberto, substituída por pena restritiva de direitos consistente em prestação de serviços à comunidade ou entidade pública na forma a ser disciplinada pelo Juízo das Execuções Criminais, pelo mesmo prazo, e ao pagamento de 177 dias-multa no valor de 1/30 do salário mínimo vigente na data dos fatos, por infração aos art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06.

E - Demais deliberações

Pela natureza da sanção o réu poderá recorrer em liberdade. Expeça-se alvará de soltura.

Transitada em julgado a presente sentença condenatória ou eventual acórdão condenatório:

Autorizo a destruição dos entorpecentes. Oficie-se.

Determino a destruição dos objetos apreendidos. Oficie-se.

Elabore-se o cálculo da multa e das custas processuais, acaso não se trate de réu beneficiário da Gratuidade da Justiça, e

Realize-se o abatimento dos valores atualizados, nos moldes determinados pelo art. 479 das NSCGJ. Por fim, (iv) intime-se o condenado para recolhimento do eventual saldo devido, no prazo legal de 10 dias.

Caso transcorra o prazo em questão sem pagamento, em conformidade com o disposto no art. 479-B das NSCGJ, expeça-se certidão da sentença e dê-se vista, em seguida, ao Ministério Público para que ele próprio promova a execução da multa nos moldes do art. 51 do Código Penal.

No mais, façam-se as anotações e comunicações de praxe, inclusive para o Instituto de Identificação Criminal e para o Tribunal Regional Eleitoral competente, para fins do art. 15, inciso III, da CF.

Oportunamente, arquivem-se os autos.

Intime-se.

P. R. I. C.

Osasco, 04 de outubro de 2022.